

教授Xと学生Yは、次の【事例】における甲の罪責について後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、Vが宅地造成地に駐車して所有・占有していたパワーショベルを盗もうと思い、重機販売業者の乙に前記パワーショベルを同所から搬出させた。

【会話】

教授X. 【事例】において、甲が、事情を全く知らない乙に対し、前記パワーショベルは甲の所有・占有である旨説明して売却し、乙に前記パワーショベルを搬出させたという事実関係があるとしましょう。甲の罪責はどうなりますか。

学生Y. パワーショベルを搬出したのは乙ですが、乙は、事情を全く知らず、規範的障害のないままパワーショベルを搬出したので、乙には窃盗罪の①(ア. 故意・イ. 法益侵害)がないと思います。甲は、乙を道具のように利用してVのパワーショベルを盗んだので、窃盗罪の間接正犯が成立すると思います。

教授X. 甲には、いつの時点で窃盗罪の実行の着手が認められるのですか。

学生Y. 私は、実行の着手は法益侵害の具体的危険が発生した時に認められると考えた上で、間接正犯の場合には、被利用者の行為開始時に実行の着手が認められると考えます。したがって、②(ウ. 乙が甲との間でパワーショベルを購入する契約を締結した時に・エ. 乙がパワーショベルを搬出する作業を開始した時に)、甲には実行の着手が認められると思います。

教授X. では、【事例】において、甲が、パワーショベルを盗むため、事情を知らない乙に先ほどと同様の説明をして売却したが、その後、乙が、宅地造成地に向かう途中で甲の計画にたまたま気づき、自分のものにするつもりでパワーショベルを盗むことを自ら決意して搬出したという事実関係があるとしましょう。先ほどの場合と何か違ってきますか。

学生Y. 乙は、盗むことを自ら決意してパワーショベルを搬出したのですから、乙には窃盗罪の③(オ. 正犯・カ. 幫助犯)が成立します。そして、乙には、パワーショベルを搬出する前に甲の計画を知って規範的障害が認められるので、もはや甲の道具とはいえませんが、したがって、乙が搬出した行為を甲の実行行為と評価することはできません。

教授X. その場合の甲の罪責はどうなりますか。

学生Y. 甲は、間接正犯を犯す意思で、客観的には乙に窃盗を決意させたので、甲には、窃盗既遂罪の④(キ. 幫助犯・ク. 教唆犯)が成立すると思います。

教授X. これはY君の考え方とは異なるのですが、間接正犯の実行の着手時期につき、利用者が被利用者を道具として利用した時点とする考え方に立った場合、結論はどのように変わりますか。

学生Y. 甲には、窃盗既遂罪の④(キ. 幫助犯・ク. 教唆犯)のほかに、⑤(ケ. 窃盗未遂罪・コ. 窃盗既遂罪)の間接正犯が成立すると思います。

- ①ア ②エ ③オ ④ク ⑤ケ
- ①イ ②ウ ③オ ④キ ⑤コ
- ①ア ②エ ③オ ④ク ⑤コ
- ①イ ②ウ ③カ ④キ ⑤コ
- ①ア ②エ ③カ ④キ ⑤ケ

No183

共通H26-17

間接正犯と教唆犯

正解

1

正答率

84%

() には順に、「①ア ②エ ③オ ④ク ⑤ケ」と入り、したがって、正解は肢1となる。

①について

①には、窃盗罪の「ア. 故意」と「イ. 法益侵害」のうち、乙に欠けるものが入る。学生Yの第1発言によると、乙は「事情を全く知らず、規範的障害のない」者であるから、乙には故意がない。他方、乙は、被害者Vの占有するパワーショベルをその意思に反して搬出しており、Vの占有を侵害しているので、窃盗罪の法益侵害が生じている。したがって、①には「ア. 故意」が入る。

②について

②には、実行の着手を法益侵害の具体的危険が発生した時に認められるとした上で、間接正犯における実行の着手を被利用者の行為開始時に認める見解に立った場合の、本問事例で実行の着手が認められる時点に関する記述が入る。この見解に立った場合、窃盗罪の実行の着手は他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められることになるから、本問事例では、乙がパワーショベルを搬出する作業を開始し被害者Vのパワーショベルの占有を侵害する具体的危険が発生した時点で実行の着手が認められる。したがって、②には「エ. 乙がパワーショベルを搬出する作業を開始した時に」が入る。

③について

③には、教授Xの第3発言の事実関係において、乙に成立する窃盗罪の正犯と幫助犯の別が入る。学生Yの第3発言より、乙は「盗むことを自ら決意してパワーショベルを搬出した」者であるから、正犯者の意思をもって、自ら実行行為を行い結果を惹起した者といえるので、乙には窃盗罪の正犯が成立する。したがって、③には「オ. 正犯」が入る。

④について

④には、「間接正犯を犯す意思で、客観的には乙に窃盗を決意させた」場合に成立する共犯類型が入る。教唆とは、人に犯意を生じさせて犯罪を実行させることをいい、幫助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行を容易にすることを意味する。したがって、④には「ク. 教唆犯」が入る。

⑤について

⑤には、教授Xの第3発言の事実関係において、間接正犯の実行の着手時期につき、利用者が被利用者を道具として利用した時点とする考えに立った場合の、甲に成立する間接正犯が入る。甲には、乙との間で契約を締結した時点で、乙を道具として利用した行為が認められ、実行の着手が認められる。その後、学生Yの第3発言より、甲の窃盗罪が既遂に達する前に、乙の道具性が失われているので、甲には窃盗罪の未遂罪が成立する。したがって、⑤には「ケ. 窃盗未遂罪」が入る。